

0001013-41.2018.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Carmezim Camargo Neves

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009).

"TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

1ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001013-41.2018.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001013-41.2018.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF - 595/2018 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSWALDO TRINDADE JUNIOR

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Carmezim Camargo Neves

Vistos.

OSWALDO TRINDADE JUNIOR, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 34 da Lei nº 11.343/06, cumulado com o art. 69 do Código Penal, porque, no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 13h15min, na Rua Cinco, nº 31, Parque Salerno, Jardim Nova Veneza, nesta cidade e Comarca de Sumaré, guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico.

Segundo a denúncia, o acusado guardava 50 (cinquenta) frascos contendo lanças perfumes, 02 (dois) tablets de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com o peso de 740g (setecentos e quarenta gramas), uma porção fracionada da Cannabis Sativa L ("maconha"), contendo 265g (duzentos e sessenta e cinco gramas), 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) porções de cocaína, 48 (quarenta e oito) pedras de "crack", 350 (trezentos e cinquenta) porções de maconha, 01 (uma) pedra grande de "crack", pesando 115g (cento e quinze gramas).

Também mantinha sob sua guarda papel filme, geralmente utilizado para embalar

drogas, uma balança de precisão, e duas caixas de lâmina, geralmente utilizados para separar droga.

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 160/161).

Denúncia recebida em 04 de julho de 2018 (fls. 166/167).

Audiência de instrução e julgamento com colheita de prova oral, interrogatório do acusado (fls. 208 e 243).

Alegações finais do Ministério Público pela procedência do pedido, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia (fls. 250/256).

Alegações finais da Defesa pela improcedência da denúncia, alegando absoluta falta de provas. Pede a absolvição (fls. 259/271).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar não prospera. A denúncia, embora sucinta, descreve os fatos à saciedade e aponta ao acusado a conduta de "guardar" drogas, o que, coincide com o relato dos policiais militares, segundo os quais os entorpecentes foram localizados nas dependências da residência daquele. A questão envolvendo as drogas encontradas numa pochete serão analisadas quando da incursão do mérito e em nada macula a descrição da acusação quanto ao restante de entorpecente encontrado durante a ocorrência policial.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

Já o artigo 34 da Lei n. 11.343/06, assim descreve o delito:

"Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitiva.

A materialidade vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência nº 595/2018 (fls. 9/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15 e 16), pela auto de entrega (fls. 17), pelos laudo de exame toxicológico atestando positivo para as drogas descritas na denúncia (fls. 142/150 e 322/353) e pela prova oral colhida.

A testemunha Jorge Luiz Lustosa, em Juízo, disse que, no dia, foi ao local comprar drogas. Chegando lá avistou um rapaz armado, momento em que a Polícia chegou. Ambos correram assustados e foram alcançados pelos agentes de segurança. O acusado, durante a ocorrência, saiu de sua casa em posse de um saco de lixo preto e acabou sendo abordado também pelos policiais. Acompanhou a abordagem, mas não soube dizer onde foi encontrada a pochete com drogas, se perto ou longe da casa do acusado. Disse não conhecer o acusado.

O policial militar Ricardo Trujilho do Prado, em Juízo, afirmou que, em posse de denúncia anônima de tráfico de drogas com descrição das características do suposto traficante, rumou até o local. Tomou conhecimento de que foi encontrado um colete balístico, uma coronha de arma e drogas no local em área cujo acesso só é possível pela residência do acusado, mas não presenciou as diligências realizadas, pois ficou responsável pela vigilância da viatura. Com o acusado foi encontrado "maconha". Reconhece o acusado como sendo a pessoa abordada naquela oportunidade, cujas características condiziam com aquelas passadas pelo delator anônimo.

O policial militar Alexandre Nogueira Gonçalves, em Juízo, disse que, na data dos

fatos, recebeu uma denúncia anônima de tráfico de drogas em local de difícil acesso. Diante dessas circunstâncias, foi necessário um planejamento com outras viaturas para que fosse feita incursão bem sucedida no local. Ao acessarem o local pela viela que dava de encontro à residência do acusado, avistou um indivíduo que se evadiu. Apreenderam, ainda, uma pochete com drogas. Relatou que, após um tempo, depararam-se com o acusado, o qual possuía as características descritas na denúncia anônima, conhecido como "alemão". Por fim, foi realizada a vistoria no local, foi encontrada a droga.

A testemunha Danyelle Araujo Marques, em Juízo, disse que, após levar a sua filha à escola, avistou os policiais pelo local, já havendo um indivíduo detido naquele momento. Alegou que presenciou o acusado saindo de sua residência com um saco de lixo, ocasião em que foi abordado pelos policiais militares. Daí, então, os policiais tiveram acesso ao interior do imóvel, cuja entrada foi franqueada pela esposa do acusado. Alegou que, após isto, os policiais retornaram e informaram, entre eles, que não haviam encontrado droga no interior da casa; após, foram encontradas drogas em um matagal próximo à residência. Relatou que se trata de área verde, onde há diversas casas aglomeradas. Afirmou que havia diversos policiais realizando as diligências e populares próximos ao local.

O acusado, em Juízo, negou os fatos. Disse que, na data dos fatos, foi levar o filho ao ponto de ônibus. Retornou à residência e, após almoçar, foi colocar o lixo para fora, momento em que avistou um indivíduo sentado com uma "pochete" contendo drogas. Disse que, em ato contínuo, foi abordado e revistado pelos policiais militares que ali se encontravam; negou tivesse sido encontrado droga com ele. Afirmou que, posteriormente, sua mulher saiu da residência para verificar o que estava ocorrendo, quando então os policiais militares adentraram no interior da sua residência a fim de efetuar diligências. Nada foi encontrado pelos policiais. Disse que, após isto, os policiais começaram a procurar as drogas pelas redondezas da casa. Relatou que os policiais solicitaram o apoio do canil, sendo, então, encontrado um colete e drogas no interior de um saco próximo ao local. Em que pese todo o esforço pela combativa Defesa, nada há a macular a prova produzida pela acusação, a qual está em total alinhamento com os elementos constituídos na fase policial.

A delação anônima que deu origem à diligência policial está representada no documento que segue por cópia a fls. 13. Trata-se de relatório da "Rádio Patrulha", que descreve, com riqueza de detalhes, as pessoas envolvidas, características pessoais e, inclusive, a conferir ainda mais verossimilhança a seu conteúdo, quantidade e natureza dos entorpecentes lá guardados.

A partir daí foi planejada uma incursão no local, de difícil acesso, que resultou na prisão do acusado, cujas características, segundo ambos os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, afirmaram categoricamente assemelhavam-se àquelas consignadas na denúncia anônima.

Embora, de fato, não exista elemento de convicção que permita atribuir as drogas encontradas em pochete na via pública ao acusado, houve apreensão de mais entorpecentes "pelo corredor que acessava aos fundos do imóvel" e no "telhado acima de onde estavam os frascos de lança perfume"; as demais drogas, em princípio, foram localizadas "aprofundando pelo corredor" da casa, segundo relatos do policial militar Alexandre, ratificados em Juízo. As fotografias de fls. 97/98, a propósito, ilustram bem o relato.

Já a área verde à qual tiveram acesso só era passível de incursão através da residência do acusado. A Defesa, conquanto questione em alegações finais esses relatos, insistindo na tese de que os entorpecentes, a bem da verdade, foram encontrados em área verde, nada prova nesse sentido. Limitou-se a trazer fotos do suposto local (fls. 265/266) onde levada a efeito a operação; não há, contudo, nada a confirmar que se trata mesmo dos fundos da casa do acusado. Inexiste qualquer sinalização nas fotografias colacionadas a permitir qualquer identificação; nem mesmo se trouxe aos autos imagens de satélite (Google Maps, a título de exemplificação) que pudesse aferir que a região retratada nas fotografias refere-se, efetivamente, à Rua Cinco, nº 31, Parque Salerno, Jardim Nova Veneza. Aliás, considerando que as fotografias já integravam os autos desde quando

realizada a audiência de custódia (fls. 90/100), a Defesa poderia muito bem ter solicitado aos policiais militares, quando de sua oitiva em Juízo, que confirmassem ou não se as fotos correspondem ao local da diligência e até mesmo solicitar que apontassem onde as drogas e demais objetos foram encontrados. Nada fez nesse sentido. Tiveram, acusado e Defesa, plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes. Não há sequer pedido de constatação ou descrição da área, do imóvel e/ou de eventuais confrontantes por profissional de confiança do Juízo.

No mais, as declarações da testemunha de Defesa no sentido de que os policiais teriam afirmado a inexistência de drogas na residência, além de pouco crível, apresenta-se como prova absolutamente isolada nos autos, sem nada a lhe respaldar. Assim, à míngua de provas de que as drogas foram, de fato, encontradas em local de acesso comum à comunidade e não nas dependências da casa do acusado, prevalecem aqui as palavras dos policiais militares, os quais nem mesmo conheciam o acusado, não havendo, pois, indicativo de que quisessem prejudica-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime de tamanha gravidade.

Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais militares quisessem prejudicar o acusado imputando-lhe falsamente a prática do crime.

É bem verdade que a palavra dos policiais militares na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os guardas municipais foram ouvidos em Juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, presente o réu e seu defensor, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009).

"TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso". (TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 20.08.2013).

E embora a douta Defesa tenha, com efeito, trazido elementos a indicar que o vício do acusado em drogas, tal evidência não exclui a imputação levada a efeito. É perfeitamente possível – e não raras vezes constatada – a coexistência da condição de usuário/traficante; aliás, a experiência revela que, frequentemente, tratam-se de conceitos em perfeita simbiose, já que o usuário vende entorpecente justamente como meio de sustentar o vício.

Inexistem, ademais, excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

No mais, a quantidade de droga e a forma de acondicionamento permitem a segura conclusão de que o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico. Não há cogitar, portanto, de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. DO ART. 34 DA LEI Nº 11.343/06.

Neste ponto, em que pese todo argumentado pelo Ministério Público, é imperiosa a absorção deste delito por aquele previsto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal.

As circunstâncias da causa e o contexto no qual foram apreendidos os petrechos e o entorpecente indicam que o crime descrito no art. 34 serviu como meio para o cometimento do tráfico de drogas (art. 33, caput). Isso porque, o acusado, transcendendo a proibição meramente formal de guardar petrechos, chegou à consumação do tráfico, caracterizando-se, assim, crime único. A apreensão de balanças de precisão, embalagens e demais objetos comumente utilizados para embalar e individualizar as porções de drogas somente reforça a tese de que o acusado se dedicava ao comércio de entorpecentes; no entanto, não acarreta a condenação pelo crime capitulado no artigo 34 da Lei Antidrogas. A guarda de petrechos será considerada como circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

"(...) 3. Os arts. 33, § 1º, I, e 34 da Lei de Drogas - que visam proteger a saúde pública, com a ameaça de produção de drogas - tipificam condutas que podem ser consideradas mero ato preparatório. Assim, evidenciado, no mesmo contexto fático, o intento de traficância do agente (cocaína), utilizando aparelhos e insumos somente para esse fim, todo e qualquer ato relacionado a sua produção deve ser considerado ato preparatório do delito de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Aplica-se, pois, o princípio da consunção, que se consubstancia na absorção do delito meio(objetos ligados à fabricação) pelo delito fim(comercialização de drogas). Doutrina e precedentes. (...) (STF, HC nº 109708/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, J. 23.06.2015, DJe 31.07.2015)

Configurado, assim, o delito de tráfico (art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06), cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa: Dentre as circunstâncias judiciais a serem analisadas com preponderância àquelas do art. 59 do CP (art. 42, da Lei n. 11.343/06), observo que não são inteiramente favoráveis.

Isso devido à natureza das drogas, crack e cocaína, substâncias com alto poder viciante, destrutivo e vulnerante; possui natureza deletéria diferenciada de outras substâncias entorpecentes, apta a atingir um número significativo de usuários, disseminando o vício na sociedade e causando grave perigo ao bem jurídico da saúde pública, razão pela qual deve o Estado manter uma postura mais rígida diante deste tipo de crime e, em especial, deste tipo de entorpecente.

Levo em conta, também, a considerável quantidade de droga apreendida em sua casa, a superar três quilos, aumentando a ofensividade da conduta.

A variedade da droga também é digna de nota, pois apreendidas cocaína, maconha e crack.

As circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, por sua vez, não são favoráveis.

As circunstâncias do crime são relevantes. Isso porque, não bastasse a quantidade de droga encontrada, o acusado mantinha em referido imóvel objetos para produção, armazenamento e fracionamento de droga e, ainda, outros objetos como colete balístico.

Assim, e à míngua de outras circunstâncias judiciais a valorar, fixo a pena base acima do mínimo legal, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. Segunda etapa: Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Terceira etapa: Inaplicável, por sua vez, o redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Isto porque tal privilégio tem lugar a quem, de fato, por um desvio de conduta, optou pelo tráfico. Tal redutor premia, em outras palavras, o traficante de primeira viagem. Não é o caso, contudo, dos autos. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, o que permite abastecer o vício de um sem número de usuários, indica que seu perfil não se subsume àquele que o legislador pretendeu atingir com a elaboração do §3º. Pelo contrário, traz indícios concretos de seu acentuado

envolvimento no mundo do tráfico; ora, só quem se dedica com afinco a essa finalidade recebe tamanha quantidade para comércio. Reforça essa premissa os demais objetos encontrados no local, sobretudo os incontáveis papéis de caderno contendo indubitosa contabilidade do tráfico (fls. 334, 335, 336, 337), todas datadas e apreendidas juntos ao entorpecentes, prova irrefutável da habitualidade criminosa, desvelando que o acusado fazia do tráfico de drogas seu meio de vida. Desta feita, deixo de aplicá-lo. Por consequência, torno definitiva a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: A quantidade da pena privativa de liberdade e a circunstâncias judiciais desfavoráveis, reputo adequado a fixação do regime FECHADO para o início do cumprimento da pena (artigo 33, §3º, c, do Código Penal).

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo-se em vista que as circunstâncias judiciais não indicam que tal medida seja suficiente a atender o aspecto retributivo (imposição de uma sanção ao causador do delito) e o preventivo (estímulo ao cumprimento das normas de conduta) da pena.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar OSWALDO TRINDADE JÚNIOR à pena de reclusão, pelo prazo de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O acusado teve sua liberdade provisória decretada. De lá para cá não houve superveniência fática a justificar a reanálise dos pressupostos, fundamentos e requisitos da prisão preventiva, pelo que poderá responder em liberdade.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois a progressão de regime deve observar não tempo de custódia (requisito objetivo), mas também o bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), conforme art. 122, da LEP; aqui, porém, além de ausente o requisito objetivo, não há qualquer notícia de eventual bom comportamento carcerário do acusado, de modo a impossibilitar, de imediato, a progressão de regime ou a consideração do período de custódia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Além disso, compete ao juiz de execução decidir sobre a progressão de regime, conforme art. 66, III, b, da LEP; afinal, é ele que possui as informações completas sobre o comportamento carcerário da pessoa custodiada.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento dos objetos apreendidos em favor da União Federal, conforme artigo 36 da Lei n. 11.343/06.

Se o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado no valor correspondente à espécie processual praticada.

Publica-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sumare, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA